

1507032-85.2021.8.26.0344

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Favorecimento real

Magistrado: Josiane Patricia Cabrini Martins Machado

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/09/2022

... estar diante da eventual hipótese de tráfico de drogas. Nesse sentido, a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. POSSE DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não se aplica o princípio da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

1ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, Marília - SP - cep 17519-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1507032-85.2021.8.26.0344 - lauda

CONCLUSÃO

Em 29 de agosto de 2022, faço os autos conclusos à MM. Juíza de Direito, Dra. Josiane Patricia Cabrini Martins Machado. Eu, Juliana Baccelli Fernandes Cunha, M364719, subscrevi.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507032-85.2021.8.26.0344 - Controle 2021/001508

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Favorecimento real

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SÉRGIO DE OLIVEIRA SOARES JUNIOR

Vistos.

SÉRGIO DE OLIVEIRA SOARES JUNIOR (RG: 53.379.504, filho de Sérgio de Oliveira Soares e Angela Moraes da Silva) foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal e artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal, porque, em data anterior e no dia 26 de março de 2021, às 15h, na Rodovia SP 294, estabelecimento prisional, nesta cidade e Comarca de Marília, recebeu, em proveito próprio, um telefone celular, da marca Positivo, coisa que sabia ser produto de crime, bem como trazia consigo, para fins de consumo próprio, 5,45g de Cannabis Sativa L, vegetal conhecido como maconha, sem autorização e em desacordo com determinação regulamentar ou legal. Recebida a denúncia em 20 de setembro de 2021 (fls. 66/67), o réu foi citado (fls.

77) e apresentou resposta à acusação (fls. 80/86).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas as testemunhas arroladas e, em seguida, realizado o interrogatório do acusado.

Alegações finais ministeriais e defensivas constantes do termo de audiência retro.

É o relatório. Fundamento e decido.

O pedido inicial é procedente.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelos boletins de ocorrência (fls. 3/4 e 36/37), autos de exibição e apreensão (fls. 5 e 38), procedimento administrativo (fls. 7/35), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 40/44), auto de avaliação (fls. 95), laudo pericial de aparelho celular (fls. 97/104) e pela prova oral colhida. A autoria também é certa.

Na fase administrativa (fls. 20/23), os agentes penitenciários Fábio, Carlos e Breno declararam que, em 26 de março de 2021, por volta das 15h, realizaram revista na ala C, do anexo semiaberto da Penitenciária de Marília. Durante a inspeção, localizaram uma abertura na parede do banheiro de uso coletivo dos sentenciados, local que guardava um fone de ouvido, dois carregadores para telefone, bem como um aparelho celular, da marca Positivo. Ao término da vistoria, questionaram todos os presos daquela ala a quem pertencia os objetos e, de pronto, SÉRGIO assumiu a propriedade dos bens supracitados. Na sequência, os agentes Fábio e Breno encaminharam o acusado até a cela disciplinar e submeteram-no a revista pessoal, oportunidade em que encontraram, na cueca do réu, uma porção de uma substância que aparentava ser maconha. Em juízo, os agentes Fábio e Carlos corroboraram a versão prestada na Delegacia. Inclusive, Fábio esclareceu que, durante a execução de revista na cela, os sentenciados são retirados do local e, se algo de ilícito for encontrado, os reclusos da ala são chamados e indagados acerca da propriedade dos objetos, sendo certo que o réu se apresentou como proprietário do aparelho celular. A testemunha Breno de Mello Rodrigues foi ouvida apenas em fase inquisitiva.

O acusado, em solo policial (fls. 17/18 e 47/48), confessou parcialmente os fatos. Disse que em seu alojamento, numa inspeção de rotina, foi localizado um aparelho celular. Na ocasião, se declarou proprietário do objeto. Após, ao ser submetido a revista pessoal, encontraram com ele uma porção de drogas. Revelou que realmente era dono do entorpecente, negando, porém, a propriedade do telefone. Ainda, explicou ter realizado um acordo com os demais sentenciados para que assumisse o celular como seu, a troca de ajuda financeira a família. Em seu interrogatório judicial, repetiu as informações apresentadas anteriormente. Negou a propriedade, bem como o uso do aparelho celular. Admitiu, entretanto, que tinha conhecimento do telefone na cela, e que era proprietário da droga.

Ora, da análise da prova produzida, verifica-se que restaram comprovadas as práticas delitivas pelo acusado.

Com efeito, os depoimentos dos agentes penitenciários têm fé pública, os quais narraram os fatos de forma uníssona e harmônica desde a fase inquisitiva, repetindo as versões em juízo. Segundo consta dos autos, em 26 de março de 2021, por volta das 15h, agentes penitenciários realizaram inspeção de rotina na ala C do anexo do regime semiaberto da Penitenciária de Marília. No local, encontraram um fone de ouvido, dois carregadores para telefone, bem como um aparelho celular, da marca Positivo, todos localizados no interior de um buraco na parede do banheiro.

Indagados pelos agentes, SÉRGIO assumiu a propriedade dos bens apreendidos. Logo depois, o acusado foi encaminhado a uma cela da inclusão e submetido a uma revista pessoal, sendo encontrada, no interior de sua cueca, uma porção de substância análoga a maconha.

Quanto à receptação, ao contrário do sustendo pelo douto Defensor, irrelevante apurar se o telefone figuraria como objeto de um crime anterior, porquanto a mera introdução do aparelho em unidade prisional configura crime, nos termos do artigo 394-A do Código Penal. Portanto, trata-se de delito antecedente necessário à tipificação da receptação, ora analisada nos autos.

Do mesmo modo, insubsistente a invocada tese de atipicidade no que toca ao delito patrimonial. Nesse sentido: "Sob enfoque diverso, o elemento subjetivo e a ciência da origem espúria do bem se mostram incontestáveis, ainda mais porque todos os presos são informados da proibição de ingresso de celulares e respectivos

acessórios em unidades prisionais (sob pena de prática do crime do artigo 349-A do CP) (TJSP; Apelação Criminal nº 1506058-02.2019.8.26.0576; Rel. Farto Salles, 6ª Câmara de Direito Criminal, j. 16/03/2022) "APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPÇÃO DE APARELHO CELULAR NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL - Absolvição - Impossibilidade - Conjunto probatório que torna indubitáveis a materialidade e a autoria do delito, bem como o conhecimento acerca da origem ilícita do objeto - Confissões que encontram abrigo nas declarações dos agentes penitenciários - Réus que agiram em comparsaria, ocultando e utilizando o bem em questão - Atipicidade por ausência de crime antecedente - Descabimento - Ingresso de celular em estabelecimento prisional que fatalmente se deu de forma criminosa, caracterizando o aparelho objeto ilícito, por suas próprias peculiaridades (quando em poder de presos), e não mero instrumento do crime disposto no art. 349-A do CP - Condenações mantidas - Pena criteriosamente dosada - Impossibilidade de compensação entre a confissão e a reincidência - Agravante preponderante, nos termos do art. 67 do CP - Precedentes - Gravidade concreta dos fatos, aliada à condição de reincidentes dos acusados, que reclama pela manutenção do regime fechado - Recursos não providos" (TJSP; Apelação Criminal nº 0004211-70.2011.8.26.0430; Relator Camilo Léllis, 4ª Câmara de Direito Criminal, j. 28/11/2017).

Deste modo, a introdução de telefone celular em qualquer unidade prisional configura crime e, por isso, aqueles que o adquirem ou recebem praticam o delito de receptação, por se tratar de objeto de origem ilícita.

Ademais, não prospera a alegação do acusado de que tenha se apresentado como proprietário dos ilícitos encontrados em sua cela (a saber, um aparelho celular, um fone de ouvidos e dois carregadores) apenas por acordo ajustado com os demais detentos dali, pois assumiu espontaneamente a propriedade no momento que foi indagado pelos servidores e, após, a negou em clara e simples tentativa de eximir-se da culpa, restando isolada nos autos a versão, não sendo corroborada por nenhuma outra prova.

De se ressaltar não há motivos para desmerecer os depoimentos dos agentes de segurança, sobretudo porque o réu não demonstrou que as testemunhas quisessem prejudicá-lo de forma gratuita e deliberadamente. Vale dizer que inexistem nos autos dados concretos no sentido de que as testemunhas ouvidas em Juízo, sob compromisso, quisessem mentir.

Neste caso, resta comprovado que o acusado recebeu, em proveito próprio, um aparelho celular, embora soubesse que se tratava de produto de crime (já que proibido o ingresso de celulares em estabelecimento prisional). Ainda, o recebimento e ocultação do objeto também é ato ilícito, logo, quem o recebe pratica o crime de receptação dolosa, tendo, o réu, plena consciência desta proibição.

No caso concreto, pois, evidente que o réu sabia que o celular era produto ilícito, ante à proibição mencionada. Mas ainda que assim não fosse, observa-se que a prova de haver conhecimento da origem ilícita dos objetos também pode ser indiciária ou circunstancial, deduzida da própria conduta do agente e dos fatos que envolvem a infração (arts. 157 e 239 do CPP, combinados; RT395/309, 401/285; RJDTACrimSP 5/169, 19/75-147). Com efeito, "Para a fixação do tipo definido no art. 180 do CP, é indispensável que o agente tenha prévia ciência da origem criminosa da coisa. No entanto, tratando-se de um estágio do comportamento meramente subjetivo, é sutil e difícil a prova do conhecimento que informa o conceito do crime, daí porque a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a infração e a própria conduta do agente." (JUTACRIM/SP, vol. 83/242).

Ora, não se olvida que o artigo 239 do Código de Processo Penal define o que vem ser indício e a doutrina o entende como meio de prova indireta ou de caráter lógico. Sua força probante, em razão do livre convencimento do juiz, é equivalente a qualquer outro meio de prova. No presente caso, a certeza da circunstância indiciária confere aos elementos de prova carregados validade suficiente a formar convencimento desfavorável ao acusado, uma vez que são coerentes e concatenados, a gerar a certeza necessária à condenação.

Certo é que tal meio de prova, pela sua veemência, tem sido admitida por nossos pretórios (vide RT 709/330, 711/336, 739/626 e 746/629). Observe-se, outrossim, que o acórdão inserto na Revista dos Tribunais, vol. 728, pág. 543, aplicou exatamente

este meio de prova para o reconhecimento de receptação dolosa.

Por conseguinte, tendo em vista que não há meios legítimos para que um telefone celular chegue às mãos de um preso, pois é bem revestido de peculiaridades que possibilitam sua comunicação com o exterior, o que, evidentemente, não é permitido, a presença de tal objeto em unidade prisional e em poder de algum detento, como é o caso, é sim, o bastante para torná-lo ilícito (tanto que tipificada, tal conduta, no Código Penal).

Quanto ao crime previsto no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06, também restou configurado, na medida em que SÉRGIO trazia consigo, para fins de consumo próprio, cerca de 5,45g de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação regulamentar ou legal.

O laudo de exame químico-toxicológico concluiu tratar-se, o entorpecente apreendido, de maconha (fls. 40/44).

Assim, salienta-se que as teses defensivas devem ser afastadas. A tese de inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 não vinga, porque o artigo está em pleno vigor, contando, inclusive, como medida para evitar a penalização de usuários de drogas com a privação de liberdade. Ou seja, atende todos os ditames constitucionais de direito à saúde e tratamento de viciados, inclusive com possibilidade de remessa a cursos, além da advertência quanto aos males causados pelo vício em entorpecentes. Não afronta, por conseguinte, qualquer dispositivo constitucional, seja de direito penal ou envolvendo direito à saúde pública. Ainda, de se ressaltar que não há violação a quaisquer outros princípios. Isso porque o delito em questão viola o bem jurídico "saúde pública", que é, por sua vez, tutelada pelo Estado. Se tivesse optado pela descriminalização da conduta praticada pelo réu, não teria ele, quando da edição da Lei de Drogas, tipificado no artigo 28. Optou o legislador por assim fazer por entender que não cabia, no caso concreto, a intervenção mínima e que o Estado deve coibir, de alguma forma, o uso de entorpecentes, ainda que com medidas menos gravosas que a restrição da liberdade. O fato das drogas criminalizadas estarem listadas em portaria do Ministério da Saúde não torna a norma penal inconstitucional. Foi apenas outra escolha legislativa.

Ademais, conforme já ressaltado, aqui o princípio da intimidade dá lugar à proteção à saúde pública, bem universal e corretamente tutelada pelo Direito Penal. Nenhum princípio, de se lembrar, é absoluto, e o interesse privado cede ao interesse público. Também não há que se falar no reconhecimento da atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância, eis que, nos delitos relacionados a entorpecentes, de perigo abstrato, o que se busca é a proteção da saúde pública, de forma que a prática do delito em questão efetivamente atinge os bens jurídicos protegidos pelo Direito Penal. Além disso, a pequena quantidade de droga apreendida em poder do agente é inerente ao crime de posse de entorpecentes para uso próprio, eis que, do contrário, poder-se-ia estar diante da eventual hipótese de tráfico de drogas. Nesse sentido, a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. POSSE DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não se aplica o princípio da insignificância ao crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006), porquanto se trata de delito de perigo abstrato, e a pequena quantidade de entorpecente é inerente à própria essência do tipo penal questão. 2. Agravo regimental desprovido". (AgRg no REsp 1581713/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/8/2016, DJe 29/08/2016).

Além disso, não se pode olvidar que SÉRGIO confessou, em sede policial e em juízo, a propriedade da droga, encontrada em sua cueca.

Diante do panorama apresentado, por se enquadrar, a conduta do acusado, no conceito de fato típico e antijurídico, e não havendo excludentes de culpabilidade, a condenação é medida de rigor. Assim, afastadas as teses defensivas, passo à dosimetria da pena.

Artigo 180, caput, do Código Penal

Atenta aos requisitos constantes do artigo 59 do Código Penal, observo que o réu

ostenta maus antecedentes (fls.131/135), revelando personalidade formada para a criminalidade. Assim, fixo a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, a saber, 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase de aplicação de pena, ausentes atenuantes. Presente a agravante da reincidência (fls. 131/135), razão pela qual aumento a pena anteriormente fixada em 1/6 (um sexto), restando, assim, o cumprimento de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, mantendo-se como definitiva a pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão. A pena pecuniária é fixada em 12 (doze) dias-multa, cada qual no valor de um trigésimo do salário mínimo, reajustados a partir da data do fato, critério previsto no artigo 49, §2º, do Código Penal.

Nos termos do estabelecido no artigo 33 e seguintes do CP, considerando o quantum de pena aplicado e a reincidência do réu, fixo o regime semiaberto como inicial de cumprimento de pena. Ainda, pelos mesmos motivos, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos no caso em questão, bem como a concessão do sursis.

Artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006

Devido à condição atual do réu, que está preso, cumprindo pena pela prática de outros delitos, certamente não terá condições de frequentar cursos ou prestar serviços à comunidade em curto espaço de tempo. Logo, ser-lhe-á aplicada exclusivamente a pena prevista no inciso I, do artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial e condeno o réu SÉRGIO DE OLIVEIRA SOARES JUNIOR, qualificado nos autos, ao cumprimento das penas de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, no valor mínimo, por infração ao artigo 180, caput, do Código Penal; e à pena de advertência, pela prática do crime previsto no artigo 28, caput, da Lei n. 11.343/2006, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Em respeito ao § 1º do artigo 387 do Código de Processo Penal, diante da ausência de circunstâncias cautelares concretas e considerando que respondeu a este processo em liberdade, concedo ao acusado o direito de recorrer da presente decisão em liberdade.

Oportunamente, expeça o necessário para a execução das penas impostas e ao cumprimento desta sentença. Oficie-se ao TRE, para atendimento do disposto no artigo 15, inciso III da Constituição Federal e comunique-se ao IIRGD.

Custas na forma da Lei Estadual nº 11.608/03, observado o artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, se o caso.

P.I.C.

Marília, 30 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA